

1501545-27.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente guarde o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1501545-27.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501545-27.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE OLIVEIRA MORAES

Vistos,

I. Relatório.

FELIPE DE OLIVEIRA MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, horário e local indicados na denúncia, no Centro de Progressão Penitenciária, teria trazido consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, entorpecentes consistentes em 79,880g (setenta e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas) da substância entorpecente "Cannabis Sativa, L", popularmente conhecida como "maconha", dividida e acondicionada em 93 (noventa e três) invólucros de plástico preto envoltos incolor aderente.

O acusado foi notificado (fls.88) e apresentou defesa preliminar (fls.67/69)

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2022 (fls.79/80).

O acusado foi citado às fls.112.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e, ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, sustentando falta de provas para condenação.

É o relatório.

## II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls.11/12), auto de exibição e apreensão (fls.13), imagens fotográficas (fls.14 e 15), comunicado de evento (fls.19), laudo de exame químico toxicológico (fls. 50/51), bem como pela prova oral produzida.

Passo a análise da autoria do crime.

O acusado, em fase extrajudicial, declarou que estava preso no Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis/SP há cinco meses e, como sua família é de Piracicaba/SP, não possuem condições de visitá-lo, de modo que está sem visitas. Informou que, como não tem condições de se manter na unidade, lava as roupas dos outros reeducandos com mais condições e recebe em troca alimentos, materiais de limpeza, mas não entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos, por volta das 10h30, estava na lavanderia, lavando as roupas, quando os agentes começaram a gritar que iriam "trancar a cadeia". Aduziu que estava na lavanderia com mais outros cinco reeducandos. Disse que os outros reeducandos saíram e ele estava acabando de lavar as últimas peças, momento em que o agente adentrou. Mencionou que, em revista nos banheiros, o agente disse ter encontrado entorpecentes no vaso sanitário. Informou que foi conduzido a uma das celas da unidade e que não sabia que tipo de droga foi encontrada, pois não as viu. Salientou não ter qualquer envolvimento com drogas e que não faz parte de facção criminosa. Esclareceu que as drogas encontradas não são suas e não sabe a quem pertencem (fls.08/09). Em juízo, disse não ser usuário de drogas e informou que cumpria pena por tráfico. Negou a prática do crime. Disse que não estava na posse de drogas. Alegou que estava arrumando seus pertences, em seu quadrado, e se deparou com um agente e parou; então, chegou outro agente, vindo do banheiro, e lhe imputou a propriedade de droga. Disse ter negado a propriedade e o agente lhe falou "que seria premiado". Afirmou que nunca teve qualquer problema com as testemunhas ouvidas. Negou ter entrado no banheiro. Também negou ter drogas em pote em suas mãos. Alegou não ter dito na delegacia estar na lavanderia.

O agente penitenciário Raoni Augusto Dias Tonon, em fase extrajudicial, informou que, data dos fatos, durante o procedimento de "blitz" geral na Unidade Prisional, ao adentrar o banheiro do alojamento X, avistou o acusado em uma atitude suspeita, o qual, ao perceber sua presença, tentou correr. Mencionou que viu o momento em que o acusado jogou um pote de amaciante dentro do vaso sanitário. Aduziu que, imediatamente, retirou o pote do vaso e viu que continha 51 (cinquenta e um) invólucros de substância entorpecente semelhante a "maconha". Disse que, em seguida, ao revistar o acusado, encontrou um pote de desodorante com mais 42 (quarenta e dois) invólucros de substância entorpecente semelhante a "maconha" em uma de suas mãos, totalizando 93 (noventa e três) porções de "maconha" (fls.06). Em juízo, disse que fazia com a testemunha Jeferson processo de revista; então, entraram no alojamento, que é dividido em quadrados pela organização das camas, e tem um banheiro grande ao fundo; quando entrou no banheiro, viu o réu que, ao vê-los, correu, entrou em um "box", onde há vaso sanitário, e se desfez de um pote de amaciante; após, na mão dele, foi encontrado um pote de desodorante contendo mais

porções de droga. Explicou que localizou o porte de amaciante do vaso sanitário e que a embalagem não chegou a ser aberta. Afirmou que o colega deteve o réu enquanto pegou a droga. Informou que, de início, viu que o réu tinha algo nas mãos, mas não identificou. Depois, com revista feita também por seu colega, foi localizado um pote de desodorante nas mãos do réu, em meio a camisa, contendo outras porções de maconha, também embaladas individualmente. Relatou que ele nada falou sobre a droga.

Em juízo, o agente penitenciário Jeferson Rodrigues narrou que entraram no alojamento para realização de "blitz" e viu o réu vir do banheiro e para lá voltar. Disse que ele jogou um pote no vaso e, após revista, encontrou na camiseta que ele levava nas mãos uma embalagem de desodorante contendo porções de droga. Disse que viu o pote nas mãos do réu e ele indo ao banheiro. Informou que Raoni pegou o pote no banheiro e ele ficou na contenção do preso. Esclareceu que é comum localizar drogas nesse tipo de revista sem descobrir que é o proprietário, mas, nesse caso, não há dúvida, porque viu na mão do acusado.

Eis o teor da prova oral.

Diante da prova produzida, evidente que o réu é o autor do crime narrado na denúncia.

Os depoimentos dos agentes foram firmes, coesos e harmônicos no sentido de informar que viram o acusado dispensando no vaso sanitário um pote de amaciante contendo entorpecentes e que localizaram em suas mãos um pote de desodorante que também continha drogas.

Vale ressaltar que os próprios agentes afirmaram que há muitos casos em que não conseguem encontrar os proprietários de entorpecentes apreendidos, mas, nesse caso, não restou dúvidas quanto a autoria, vez que também havia "maconha" na mãos do réu.

No mais, não há nos autos qualquer indício de que os agentes penitenciários tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do acusado, que, inclusive, negou ter qualquer problema com eles.

Ademais, não se pode presumir que a ação do agente, investido pelo Estado, em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais militares.

Ainda, a versão do réu não encontra qualquer amparo nos autos, cumprindo ressaltar que apresentou alegações distintas na fase policial e em juízo sobre o local em que estava no momento dos fatos.

E, mesmo que o agente penitenciário não tenha visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos "(...) trazer consigo (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente guarde o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2

- Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

E, a quantidade da droga apreendida, a sua natureza, a forma do acondicionamento (no interior dos potes de amaciante e de desodorante) e o contexto dos fatos indicam claramente que o estupefaciente era destinado a terceiros.

De rigor, ainda, o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas. A prova é segura o bastante para afirmar que a prática delitiva ocorreu nas dependências do estabelecimento prisional, onde o réu estava.

Destarte, comprovada autoria e a materialidade dos delitos, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls.75). Ainda, significativa a quantidade da droga. Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo unitário.

Presente a agravante da reincidência específica (fls.76), de modo que se majora a pena em 1/5, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Ausente atenuantes.

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, a majorar a pena em 1/6, resultando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Logo, torno definitivo o "quantum" acima fixado.

Diante da pena fixada e sendo o réu reincidente, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, II e § 3º do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal)

Considerando a quantidade de pena, as circunstâncias do crime, equiparada a hediondo, bem como a reincidência outro regime que não o mais gravoso será ineficaz para iniciar o processo de ressocialização do acusado. Destarte, fixa-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.

E, o teor do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal não pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta. Isto porque incabível análise de progressão, vez que não é possível saber em sede de processo de conhecimento se o acusado está preso por este ou outro processo, qual o mérito do réu, e se houve algum incidente durante a sua prisão que altera o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo necessários ao reconhecimento do benefício. No mais, a competência originária para a análise de eventual progressão de regime é da Vara das Execuções Criminais (artigo 66, III, "b", da Lei n. 7.210).

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - ACOLHIMENTO Sendo o réu reincidente, adequada a fixação de regime

semiaberto para o início do cumprimento da pena. Detração do tempo de prisão cautelar que há de ser examinada pelo Juízo das Execuções - Recurso provido." (TJSP, Apelação 0026588-11.2011.8.26.0050, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 10/03/2014, g.n.);

"(...) Pena. Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça. Roubo circunstanciado. Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena. Entendimento. Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena. Cumprimento de prisão cautelar por lapso temporal suficiente à progressão de regime. Impossibilidade de influência na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. Entendimento. Em que pese o teor do art. 387, §2º, do CPP, a análise de pedido de fixação de regime mais brando, em razão de cumprimento de pena cautelar ou definitiva, não pode ser efetuada pelo Juízo de conhecimento, pois se confunde com um pedido de progressão de regime, a ser apreciado pelo Juízo da Execução, que é o natural para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão." (TJSP, Apelação 0020392-25.2012.8.26.0071, Relator(a): Grassi Neto, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/10/2013, g.n.);

"HOMICÍDIO - pena - base fixada no mínimo legal e reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis percorrido. REGIME INICIAL - detração - consideração do tempo de prisão processual para fixação do regime inicial - art. 387, §2º, do CPP - impossibilidade de entender-se o dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em execução - impossibilidade da progressão indireta - dispositivo legal que na verdade prevê desconto de pena processual da pena imposta para fins do art. 33, §2º, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3º, do CP, onde não se leva em conta o quantum de pena imposta - improvimento." (TJSP, Apelação 0016797-87.2012.8.26.0048, Relator(a): Lauro Mens de Mello, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/05/2015, g.n.).

Assim, eventual pedido de progressão de regime prisional há que ser deduzido ao Juízo das Execuções, que poderá aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto.

### III. Dispositivo.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar FELIPE DE OLIVEIRA MORAES, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nas sanções do artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

O réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal. Portanto, não poderá recorrer em liberdade. Em casos tais, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: "Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-

se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada" (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198). No mais, sua conduta indica ousadia e periculosidade, praticando novamente crime que tem causado a degradação do indivíduo e da sociedade brasileira dentro de estabelecimento prisional, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido e extraia-se guia de execução provisória, em caso de recurso.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Jardinópolis, 09 de novembro de 2022.

Joice Sofiati Salgado  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA